

1502131-62.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... a ser reconhecida.

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Jardim das Flores, cep 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo Digital 1502131-62.2021.8.26.0542 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502131-62.2021.8.26.0542

Controle: 2021/001535

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

MATHEUS TYBA MENDONÇA e CAIO DOS REIS PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

CAIO DOS REIS PEREIRA e MATHEUS TYBA MENDONÇA, qualificados nos autos, foram denunciados por incursos nas penas do artigo 157, §§ 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque, em 18 de setembro de 2021, por volta das 1h, na Rua Pernambucana, Conceição, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros dois indivíduos, não-identificados, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo em face de Pedro, a motocicleta pertencente a ele, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. Apurou-se que, na data do ocorrido, previamente ajustados entre eles, Caio, Matheus e outros dois indivíduos, não-identificados, a bordo de motocicletas XRE preta e Honda CG branca, avistaram a vítima em sua motocicleta, oportunidade em que se aproximaram de Pedro e, exibindo arma de fogo, anunciaram o assalto, exigindo a entrega da motocicleta.

A vítima se negou a entregar a motocicleta, a qual estava inclusive com pneu furado. Pedro logrou se desvencilhar dos agentes e empreender fuga.

Instantes após, Pedro avistou policiais militares que realizavam patrulhamento pelas imediações e lhes informou acerca da tentativa de roubo, das características físicas dos roubadores e da descrição das motocicletas utilizadas na empreitada criminosa.

Em diligências pelas proximidades do local dos fatos, os milicianos avistaram indivíduos a bordo das duas motocicletas descritas pela vítima, sendo que os que estavam a bordo da Honda CG lograram se evadir sem serem identificados, ao passo

que os que estavam a bordo da XRE preta tentaram empreender fuga, mas caíram ao solo, sendo devidamente abordados.

Caio e Matheus foram detidos. A motocicleta que eles ocupavam estava com a placa tampada por uma máscara de proteção facial.

Instada a comparecer ao Quinto D.P. Local, a vítima reconheceu Caio e Matheus, de forme inequívoca, como dois dos autores do delito, bem como a motocicleta apreendida como sendo aquela utilizada na prática delitiva.

A denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2021 (fls. 168/170) e citados Caio e Matheus (fls. 196/197). Sobrevieram as respostas escritas (fls. 186/191 e 202) e, não havendo causas de sumária absolvição, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 272/273).

Em instrução processual criminal foram ouvidas a vítima (fls. 264/265) e testemunhas (fls. 266/267), prosseguindo-se com os interrogatórios (fls. 268/270). Encerrada a instrutória, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, sendo que a Defesa requereu diligência, que foi deferida pelo Juízo (fls. 271/272). Caio e Matheus foram colocados em liberdade.

A diligência foi cumprida (fls. 298).

Em sede de memoriais escritos, a Dra. Promotor de Justiça pleiteou pela procedência da ação penal e consequente condenação de Caio e Matheus nos termos da denúncia (fls. 314/320).

A Defesa de Matheus pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso IV ou V, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, pelo afastamento dos §§ 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, artigo 157, do Código Penal (fls. 302/311).

A Defesa de Caio, por sua vez, requereu a absolvição nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, pelo afastamento dos §§ 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, artigo 157, do Código Penal (fls. 329/347).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Preliminarmente, declaro a nulidade do reconhecimento pessoal na fase policial e em Juízo.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua mais moderna jurisprudência, estabeleceu que o reconhecimento extrajudicial, seja pessoal ou fotográfico, que não observe os ditames do artigo 226, do Código de Processo Penal, não serve de lastro para embasar a condenação, ainda que o reconhecimento seja confirmado judicialmente.

“Uma reflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, leva a concluir que, com efeito, o reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar “falsas memórias”, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.). 5. Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato. 6. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do

CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial (...) 8. Tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima, deve o réu ser absolvido" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 652.284-SC. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgamento: 27 de abril de 2021).

Ora, no caso destes autos, Pedro afirmou que, quando chegou na Delegacia, os abordados estavam na mesma viatura e foram colocados em uma sala, sendo que os viu através de uma fresta. Já estava com eles dentro da viatura antes do reconhecimento (fls. 264/265). Tem-se, portanto, que não observadas as cautelas do artigo 226, do Código de Processo Penal, uma vez que não apresentada nenhuma outra pessoa para fins de reconhecimento, tornando esse ato extrajudicial nulo. Observe-se, ainda, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a inobservância das regras para fins de reconhecimento na fase policial macula o reconhecimento em Juízo, eivado de preconceção da imagem da pessoa a ser reconhecida.

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciais e, conseqüentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciais (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da

atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias). 9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado. 10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado. 11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância). 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão – SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua

reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 598.886-SC. Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz. Julgamento: 13 de abril de 2021).

Assim sendo, com fulcro no artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal DECLARO NULA a PROVA consistente em RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL e, por derivação, a PROVA do RECONHECIMENTO JUDICIAL (Supremo Tribunal Federal. R.H.C. 90.376. Relator: Ministro Celso de Mello. Julgamento: 2 de abril de 2007).

No mais, o conjunto probatório amealhado na fase judicial se mostra frágil.

Na fase policial, Pedro afirmou à Autoridade Policial que, após a tentativa de subtração de sua motocicleta, encontrou uma viatura da Polícia Militar, descrevendo as características dos agentes e das motocicletas que eles ocupavam (fls. 11). Em Juízo, narrou que detalhou as motocicletas aos policiais militares, não chegando a descrever os autores. Quando foi fazer reconhecimento, os reconheceu, pois eles usavam capacete com viseira clara e viu os olhos e nariz deles. Descreveu um dos capacetes como sendo branco com detalhes rosa, mas não conseguiu descrever as vestes dos roubadores (fls. 264/265).

A testemunha Policial Militar Alex Paulo asseverou que a vítima informou que os autores estavam em uma moto XRE preta com dois indivíduos e uma CG branca com dois indivíduos. Abordaram os autores, mas nada de ilícito foi apreendido com eles, sendo que a moto CG branca conseguiu empreender fuga. Os acusados foram conduzidos à Delegacia de Polícia na mesma viatura em que estava a vítima. Um dos capacetes era preto (fls. 266).

A testemunha Policial Militar Edilberto afirmou que a vítima informou que as motocicletas CG branca e XRE preta tentaram lhe roubar. Abordaram a motocicleta XRE preta, sendo que a motocicleta CG branca empreendeu fuga.

A vítima descreveu com riqueza de detalhes as vestes, que a moto XRE estava com uma máscara descartável tampando a placa e as características físicas dos autores. No local a vítima somente avistou os acusados de longe. Os acusados foram levados ao D.P. em outra viatura (fls. 267).

Tem-se, portanto, que as provas produzidas em Juízo são contraditórias entre si, comprometendo, todo o conjunto probatório.

"Enfim, pode-se até duvidar de uma conduta inocente por parte dos réus apelantes. É possível mesmo que reste em cada um dos agentes da lei - policiais, representantes do Ministério Público e magistrados - a íntima convicção relativa à culpabilidade dos acusados na condição de traficantes. No entanto, para uma condenação tão grave e de efeitos tão severos, o convencimento subjetivo há que restar, além das provas indiretas, minimamente provado" (TJMG - nos Autos nº 288397- 3 - j. 17/09/2002 - p. 20/09/2002).

Cabe ressaltar que, como cediço, na fase da denúncia vigora o princípio in dubio pro societatis da análise das provas e o inquérito-policial é peça meramente informativa destinada tão-somente a autorizar o exercício da ação-penal. Todavia, na sentença, se das provas emergem dúvidas da autoria, aplica-se o princípio in dubio pro reo. Neste sentido:

"Inquérito Policial - Valor deste que não pode ser tamanho que autorize a condenação apenas com seus elementos - Prova suficiente para o oferecimento da denúncia, mas não para a condenação - Absolvição mantida" (Relator: Renato Nalini - Apelação Criminal 94.764-3 - Mauá - 25.03.91).

"Inquérito policial - Natureza - Disciplina da Prova - O inquérito policial constitui mero procedimento administrativo, e de caráter investigatório, destinado a subsidiar a atuação do Ministério Público. Trata-se de peça informativa cujos elementos instrutórios - precípuamente destinados ao órgão da acusação pública - habilita-lo-ão a instaurar a persecutio criminis in judicio. A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela Polícia Judiciária na fase preliminar da persecução penal (informatio delicti) e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa à garantia

constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito. A investigação policial - que tem no inquérito o instrumento de sua concretização - não se processa, em função de sua própria natureza, sob o crivo do contraditório, eis que é somente em juízo que se torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade e da instrução criminal contraditória. A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina como pela jurisprudência dos Tribunais (RT 522/396), cujo magistério tem acentuado que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução penal em juízo. Nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia" (STF - 1ª Turma - REcr. nº 136.239-1/SP - RELATOR:- Min. Celso de Mello - DJU 14/08/92, pág. 12227).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO CAIO DOS REIS PEREIRA e MATHEUS TYBA MENDONÇA, qualificados nos autos, da imputação do artigo 157, §§ 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Osasco, 09 de fevereiro de 2022.